

1501233-30.2022.8.26.0537

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Patrícia Helena Hehl Forjaz de Toledo

Comarca: Diadema

Foro: Foro de Diadema

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/11/2022

... Teixeira foram averiguar denúncia de tráfico de drogas onde um rapaz com determinada roupa estava traficando no local indicado, que já é um ponto de venda de drogas conhecido. Ele manuseava uma pochete e não os viu. Abordado, viram que se tratava de entorpecente (cocaína, crack e maconha) e dinheiro. Questionado sobre o tráfico, o réu disse que um cara o tinha colocado para ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Diadema

Foro de Diadema

2ª Vara Criminal

Avenida Sete de Setembro, 399, Diadema-SP - cep 09912-010

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501233-30.2022.8.26.0537 - Controle nº 2022/000905

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2159247/2022 - 03º D.P. DIADEMA, 25510050 - 03º D.P.

DIADEMA, 2159247 - 03º D.P. DIADEMA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Gisley de Brito Cangusu

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Patrícia Helena Hehl Forjaz de Toledo

Vistos.

GISLEY DE BRITO CANGUSU, qualificado a fls. 08, está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, porque no dia 10 de junho de 2022, por volta das 14h48, na Travessa das Dalias, n.º 10, bairro Campanário, nesta cidade e comarca de Diadema, trazia consigo e guardava, para fins de entrega a consumo de terceiros, 12 invólucros plásticos contendo cocaína, com peso aproximado de 7,45 gramas, 19 invólucros plásticos contendo cocaína na forma de crack, com peso aproximado de 3,8 gramas e 36 invólucros plásticos contendo Cannabis Sativa L, vulgarmente conhecida como "maconha", com peso aproximado de 7,5 gramas, substâncias entorpecentes causadoras de dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 31 e laudo de constatação provisória de fls. 28/30.

Convertida a prisão em flagrante em preventiva (fls.60/63), o réu foi notificado e citado (fls.114 e 147), e apresentou defesa preliminar as fls. 122/123, através do Defensor Público nomeado. Não sendo hipótese de arquivamento, a denúncia foi recebida em 19/09/2022 (fl.130).

Em audiência de instrução, debates e julgamento, foram ouvidas as testemunhas comuns arroladas tempestivamente pelas Partes e interrogado o acusado ao final, encerrando-se a instrução processual sem requerimento de diligências, seguindo-se com os debates orais (tudo em mídia digital).

Nestes, o Órgão Ministerial requereu a procedência da ação por provadas autorias e materialidade delitivas. Pleiteou a fixação das penas base acima do mínimo diante da quantidade e nocividade da droga cocaína além dos maus antecedentes criminais do acusado, em que pese sua confissão, o que não deve preponderar sobre a multirreincidência, e sim a compensação parcial, discordando da redução da pena e de sua substituição por reprimenda restritiva de direitos, fixando-se regime prisional fechado.

Já o d. Defensor Público, diante da confissão espontânea do réu, requereu que a pena-base fosse fixada no mínimo legal, compensando-se a agravante da reincidência com a atenuante da confissão, reduzindo a pena e sua substituição, fixando-se regime mais brando, e possibilidade do acusado recorrer em liberdade, até pela detração penal.

É o breve relatório.

Passo a fundamentar e decidir.

A ação procede.

A materialidade delitiva vem estampada no auto de exibição e apreensão de fl.31, nos laudos de constatação e no definitivo (respectivamente às fls. 28/30 e 127/129), ambos positivos para as drogas cocaína e maconha.

A autoria é inconteste não só com fulcro na prova amealhada extrajudicialmente, como na colhida sob o manto do contraditório que corrobora àquela e a qual passo a expor.

Segundo narrativas administrativas dos policiais civis (fls.6/7), tomaram conhecimento via COPOM que um indivíduo que vestia camiseta azul e bermuda, comercializava drogas na Travessa das Dálias. Dirigiram-se ao local indicado, onde avistaram o ora identificado GISLEY DE BRITO CANGUSU, possuidor das mesmas características, quem trazia consigo um estojo, segurando com as mãos, o qual manipulava. O abordaram, verificaram que no estojo que ele trazia consigo havia substância semelhante a droga, a saber 36 invólucros contendo substância semelhante a maconha, 12 invólucros contendo substância semelhante a cocaína e 19 invólucros contendo substância semelhante a crack, além de R\$ 37,00. Indagado, GISLEY disse que vendia drogas no local para saldar dívida com traficantes da região.

Sob o crivo do contraditório o policial Gustavo Teixeira foram averiguar denúncia de tráfico de drogas onde um rapaz com determinada roupa estava traficando no local indicado, que já é um ponto de venda de drogas conhecido. Ele manuseava uma pochete e não os viu. Abordado, viram que se tratava de entorpecente (cocaína, crack e maconha) e dinheiro. Questionado sobre o tráfico, o réu disse que um cara o tinha colocado para trabalhar para amortizar a dívida que ele tinha com a biqueira. Reconhece o réu e não o tinha visto até então.

Igualmente o policial Thiago Ré alegou que foram acionados a averiguar denúncia de tráfico de entorpecentes com as características físicas, vestes e local onde ele

estava, já conhecido como ponto de tráfico de drogas. O réu estava no meio da viela, e o viu manuseando uma pochete, abordado, dentro tinha porções de crack, maconha e cocaína e trinta e sete reais que ele confessou ser do tráfico de drogas por ter uma dívida na biqueira para ele pagar. Reconhece o réu e não o vira antes.

O réu, em solo policial (fl.08) preferiu reservar-se ao direito de ficar calado.

Em juízo o acusado confessou que era ele mesmo e por ser usuário de crack, foi obrigado a ficar até pagar a dívida, e o dinheiro apreendido era das vendas que havia feito a usuários. Já foi processado por outros crimes antes. Estava em situação de morador de rua.

Logo, a confissão judicial e os testemunhos dos policiais - que são válidos e eficazes para a condenação condenatória, até por não haver dúvidas sobre sua lisura - estão em consonância com os demais elementos probatórios contidos nos autos, sendo corroborados pelo auto de apreensão e exibição, além das provas periciais, sem prova contrária, até porque o réu optou pelo silêncio em solo policial, mas já havia dito aos policiais que estava traficando para pagar uma dívida, o que tão pouco comprovou, e o que não o exime da responsabilidade penal.

No mais, ressalto o Enunciado 70 da Súmula de Jurisprudência do e. STJ: É cediço que no crime de tráfico de drogas, em regra, a prova é baseada nos depoimentos dos policiais. A defesa não apresentou nenhuma prova concreta capaz de ilidir as declarações dos policiais militares, não havendo motivo plausível para seu desmerecimento.

Não bastasse isso, os policiais sempre afirmaram que o réu, por eles reconhecido, foi a pessoa indicada na denúncia anônima e quem trajava as mesmas vestes citadas, estava sozinho na biqueira já conhecida, e com ele encontraram as drogas e o dinheiro proveniente da venda delas, tudo em consonância com a notitia criminis, e sem prova contrária.

Ainda que não presenciado ato de comércio, as circunstâncias do flagrante demonstram a conduta prevista no art. 33, caput, da Lei de Drogas, que consigna como verbos nucleares de guardar e trazer consigo, condutas perpetradas pelo réu, comprovada a circulabilidade. O tráfico de drogas é crime de ação múltipla e a prática de um dos verbos contidos no art. 33, caput, é suficiente para a consumação da infração, sendo prescindível a realização de atos de venda do entorpecente.

Afasto tese de estado de necessidade ou de situação de pobreza, pois os bens jurídicos são desproporcionais, por se colocar em risco a saúde pública, de interesse da sociedade, em detrimento do interesse individual, além de se tratar de crime de perigo abstrato. Isto porque não se pode confundir estado de necessidade com estado de precisão. Lamentavelmente, milhares de brasileiros passam por situação econômica desfavorável, enfrentando dificuldades para sustentar a si e seus familiares. Nem por isso se enveredam pelo caminho do crime. Ao contrário: buscam solução para seus problemas financeiros através de trabalho honesto. Sobre o tema, já se decidiu: Também não há que se falar em estado de necessidade, pois não há provas nos autos de que o apelante passava por miserabilidade extrema a ponto de ter que violar a lei para sobreviver. A mera dificuldade financeira não autoriza ninguém a praticar delitos (TJSP, Apelação Criminal n.º 0006727-87.2004.8.26.0081, Rel. Caio Ferraz de Camargo Lopasso, 5.ª Câmara Criminal D.J.E., j. em 29.07.2011). TJ/SC: Desemprego não é motivo para excludente de ilicitude de tráfico 17/08/2021 - Admitir a falta de emprego como causa excludente de ilicitude seria legalizar a prática de crimes por todo e qualquer indivíduo que esteja desempregado e em precárias condições econômicas - o que não é aceitável. O entendimento serviu de base para a 5ª câmara Criminal do TJ/SC negar apelação de um homem flagrado com meio quilo de cocaína em seu veículo, durante abordagem de policiais rodoviários.

Processo nº 5004204-68.2020.8.24.0030. Assim como a alegação do acusado de que teria sido obrigado a vender drogas para pagar uma dívida na biqueira, além de não vir provada por quem alega e, portanto, tem o ônus da prova, consoante art. 156 do CPP, não é motivo para afastar o crime nem eximir o réu da punição, até porque ele poderia ter procurado outro trabalho lícito com reciclagem por exemplo, ou mesmo procurado uma delegacia de polícia para informar sobre o aduzido constrangimento ilegal.

Por fim, a condição de usuário de drogas que o réu também informou, e não afasta a traficância, uma vez que é comumente sabido que dependentes químicos utilizam o tráfico de entorpecentes como meio de perpetuar o vício, de modo que as condutas coexistem, não se excluem, donde afastado o pedido de desclassificação. Neste sentido: A condição de usuário não elide a responsabilização do agente pelo tráfico de drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, o qual vende entorpecente para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira).

À luz do art. 28, § 2º, da Lei 11.343/06, a natureza das drogas (cocaína e maconha e crack), a quantidade de narcóticos (67 no total), o local da prisão (um ponto de venda de drogas conhecido), a apreensão de numerário proveniente das vendas de drogas (fl.31) são fatores que reunidos, permitem a conclusão indubitável de que o elemento subjetivo do agente dirigia-se especificamente à mercancia e não ao mero consumo pessoal, de modo que a procedência do pedido é inarredável. Ainda que se trate de agente que se diz usuário, situações que não se opõe, e sim coexistem.

Passa-se, pois, à dosimetria da pena.

Observado o art. 59 do Código Penal, os motivos, circunstâncias e consequências dos delitos, especialmente os maus antecedentes criminais do acusado (fl. 39 – condenação por roubo na 1ª. Vara da Barra Funda, e fl.41 – condenação por roubo na 2ª. Vara Criminal de Diadema), aqui observado que o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, não impede o reconhecimento de maus antecedentes na primeira fase da dosimetria da pena. Proibir a utilização dos maus antecedentes após cinco anos da extinção da pena retira do juiz a possibilidade de pôr em prática os princípios da isonomia e da individualização da pena – entendimento exarado no Plenário virtual do Supremo Tribunal Federal, tudo isso considerando ainda, a quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas - 67 no total, não reputo excessivo, às vistas do disposto no art. 42 da Lei de Drogas, fixo em primeira fase, a pena base acima do mínimo legal, ou seja, em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, cada um desses fixados em um trinta avos do salário mínimo vigente ao tempo do fato, tendo em conta ausência de elementos nos autos indicativos da capacidade financeira do condenado.

Em segunda fase, presente a atenuante da confissão a ser compensada com uma das reincidências, optando pela comprovada a fl. 40 (condenação por tráfico na 3ª. Vara Criminal de Diadema), e agravo a pena em 1/6 pela reincidência atestada a fl. 42 (condenação por furto na 1ª Vara Criminal de Santo André), perfazendo 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão mais 680 dias-multa.

Nesse sentido, vide recentíssima decisão do e. STJ a respeito: É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no artigo 61, inciso I do CP, sendo admissível sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. STJ - REsp 1.931.145 - grifei.

Em terceira fase, não concorrem causas de aumento de pena. Nem o privilégio previsto do §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, por se tratar de réu reincidente, específico inclusive, e a indicar que faz do crime seu meio de vida, inaplicável a ele a benesse, por expressa vedação legal. Cito jurisprudência neste sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - TRÁFICO DE DROGAS - CONDENAÇÃO ANTERIOR POR USO DE DROGAS. ART. 28 DA LEI N. 11.343/06 - REINCIDÊNCIA. COMPROVAÇÃO. REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGA. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 568/STJ. RECURSO DESPROVIDO. [...] Correto o acórdão estadual ao deixar de aplicar o redutor do art. 33, § 4º da Lei n. 11.343/2006, porquanto a reincidência, seja ela específica ou não, constitui óbice à aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, tendo em vista que um dos requisitos para a incidência do benefício é que o paciente seja primário. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp/MG, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 19/02/2018) grifo nosso.

Atenta às diretrizes do art. 33 do Código Penal, considerada a reincidência do réu, seus maus antecedentes criminais, e a quantidade de pena, fixo como adequado o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade o fechado, por entender ser o necessário e o suficiente para a reprovação da conduta e para a prevenção do crime praticado.

Incabível a benesse do art. 44 do CP, por ausentes os requisitos objetivo (pena maior que os 4 anos permitidos) e subjetivo (agente não é primário). Ademais: Entorpecente - Tráfico - Substituição de reprimenda privativa de liberdade por restritiva de direitos - Inadmissibilidade - Incompatibilidade da Lei 9.714/98 com a Lei 8.072/90, que equiparou essa espécie de crime aos hediondos, punindo o traficante com maior severidade, inviabilizando, inclusive, a concessão de benefícios, como a liberdade provisória e a progressão de regime. (TJAP) RT 772/617.

Custodiado no curso do processo, o Condenado não poderá exercer o direito de recorrer em liberdade, com mais razão ante a pena aplicada após exauriente cognição e diante do necessário resguardo da ordem pública e da aplicação da lei penal, verificada a possibilidade concreta da continuidade de práticas delitivas por plurirreincidente, e específico, bem como constatada ausência de vínculos firmes no distrito da culpa, estando desempregado. (...) Não há lógica em permitir que o réu, preso (...) durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar (...) (STF HC nº 89.824/MS Rel. Ministro Ayres Britto DJe. 28.08.2008; STJ RHC nº 111.421/RJ, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, j. 03.10.2019, DJe 10.10.2019; RHC nº 118.468/MG, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, j. 17.10.2019, DJe 25.10.2019; RHC nº 34.998/RJ Rel. Ministro Jorge Mussi DJe 20.03.2013).

Deixo de me manifestar sobre a detração penal, parecendo mais adequado que o juízo da execução se manifeste por primeiro, observando-se também o princípio constitucional do duplo grau de jurisdição, da individualização da pena e do juiz natural. Não bastasse isso, progressão de regime é matéria a ser apreciada pelo juiz da execução, competente para tanto, nos moldes do art. 112 da LEP, caso contrário, o preso provisório obteria um benefício sem se verificar, primeiramente, se preenche os requisitos da referida Lei especial, que prevalece sobre a geral. Inclusive, o réu está preso há menos de cinco meses, e sem direito sequer à progressão de regime.

Neste sentido, posicionamento do E. Superior Tribunal de Justiça: A previsão inserida no § 2.º do art. 387 do Código de Processo Penal, não se refere à verificação dos requisitos para a progressão de regime, instituto que se restringe à execução penal, mas da possibilidade de o Juízo de 1.º Grau, no momento oportuno da prolação da sentença, estabelecer regime inicial mais brando, em razão da

detração. Ainda que realizado o desconto do quantum da pena, do período em que o réu se manteve em custódia preventiva, não há óbice de que o magistrado fixe regime inicial mais gravoso, fundamentando-se nas circunstâncias do caso concreto, que recomendam maior rigor no cumprimento da pena (STJ, 5.^a Turma, HC n.º 361092/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 05/11/2015, grifei). Raciocinar em sentido contrário seria admitir uma espécie de “progressão de regime” pelo juízo criminal (que não tem competência para tanto), sem a análise dos requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos pela Lei de Execuções Penais. Não obstante, referido benefício deve ser pleiteado perante o Juízo das Execuções, ainda que em sede de execução provisória.

Por fim, não há valor mínimo de reparação do dano a ser arbitrado.

Dispositivo.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO contra GISLEY DE BRITO CANGUSU, qualificado a fls. 08, como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, e o faço para condená-lo à pena de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais ao pagamento de 680 dias-multa, cada qual fixado em 1/30 do valor do salário mínimo a época dos fatos, corrigido monetariamente à data do efetivo pagamento.

O condenado não poderá apelar em liberdade. Recomendo-o no cárcere em que está. Sendo ele assistido pela DPE, reconheço suspensa a exigibilidade de custas e despesas processuais, por ora, nos termos da Lei estadual n.º 11.608 de 2003.

Decreto a perda de valores apreendidos (R\$37,00 - fl.31), com fulcro no art. 63 da Lei 11.343/06, e determino a destruição de todas as drogas.

Com o trânsito em julgado desta sentença, opere-se a detração penal, certifique-se e extraia-se a guia de recolhimento definitiva em relação à pena corporal, encaminhando-se à V.E.C. competente, certifique-se o cálculo da pena de multa.

Oficie-se ao Senad, ao IIRGD e TRE.

Publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados. Cumpra-se.

Diadema, 22 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA